

《【문제1】 甲은 乙에 대해 1억 원의 대여금을 청구하는 소를 제기(이하 이 사건 소송이라 하며, 원금 이외의 이자나 지연손해금 등은 고려하지 않는다)하였다. 다음 물음에 답하시오. (아래의 각 물음은 독립적이며, 문제에서 제시되지 아니한 사항은 적법한 것으로 본다.) (50점)

(물음1) 원고 甲은 제1심 소송계속 중 피고 乙의 원고 甲에 대한 1억 원의 대여금 채무 전액에 대해서 연대보증한 丙을 예비적 피고로 추가하였다. 이러한 예비적 피고의 추가가 적법한지 설명하시오. (20점)》

<문제1의 물음1> 원고가 제1심 소송계속 중 연대보증인을 예비적 피고로 추가한 행위의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기한 후 제1심 소송계속 중 해당 채무를 연대보증한 丙을 예비적 피고로 추가하려는 상황이다. 쟁점으로 <소송 계속 중 제3자를 예비적 피고로 추가하는 것이 허용되는지>와 <그 요건 및 소송법상 취급>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 예비적 피고 추가의 법적 성질과 허용 여부 및 그 적법요건을 설명한다.

II. 주관적 예비적 · 선택적 공동소송의 의의와 요건

1. 의의

- 공동소송인들 사이에 법률상 양립할 수 없는 관계가 있어, 주위적 피고에 대한 청구가 인용되지 않을 것을 대비하여 예비적 피고에 대한 청구를 병합하거나, 누구에 대한 청구인지 선택적으로 판단을 구하는 형태를 말한다.

2. 성립 요건

- 민사소송법 제70조 제1항에 따르면, 공동소송인들 가운데 일부의 청구가 다른 공동소송인의 청구와 법률상 양립할 수 없어야 한다.

(1) 법률상 양립 불가능성

- 법률상 양립할 수 없다는 것은 동일한 사실관계에 바탕을 둔 권리관계에서 어느 한쪽의 권리가 인정되면 다른 쪽의 권리가 부정되는 관계를 의미한다. 예를 들어 갑이 소유자인지 을이 소유자인지와 같은 관계이다.

(2) 상호 관련성

- 각 피고에 대한 청구는 동일한 법률관계나 사실관계에 기초하여야 한다.

III. 소송계속 중 피고 추가(주관적 추가적 병합)의 허용 여부

1. 원칙적 불허

- 민사소송법은 소송계속 중 제3자를 새로운 피고로 추가하는 주관적 추가적 병합을 원칙적으로 허용하지 않는다. 이는 피고의 교체나 추가가 무분별하게 이루어질 경우 소송 절차가 지연되고 새로운 피고의 심급의 이익을 해칠 우려가 있기 때문이다.

2. 예외적 허용(민사소송법 제70조 제1항 단서)

- 과거에는 소송 제기 시에만 예비적 공동소송이 가능했으나, 2002년 민사소송법 개정을 통해 소송계속 중에도 부진정연대채무나 양립 불가능한 관계에 있는 피고를 추가할 수 있는 근거가 마련되었다. 다만, 이는 제67조 내지 제69조의 규정을 준용하는 범위 내에서 엄격한 요건 하에 허용된다.

IV. 사안의 적용

1. 법률상 양립 가능성 검토

- 주채무자 乙에 대한 대여금 청구와 연대보증인 丙에 대한 보증채무 이행 청구는 법률상 양립 가능하다. 주채무가 인정된다고 하여 보증채무가 부정되는 것이 아니며, 오히려 보증채무는 주채무의 존재를 전제로 하는 부종성을 가진다. 따라서 乙과 丙에 대한 청구는 법률상 양립할 수 없는 관계가 아니다.

2. 피고 추가의 적법성 판단

- 사안의 경우 乙과 丙은 실질적으로 연대하여 채무를 부담하는 관계이거나 주채무-보증채무의 관계에 불과하므로, 민사소송법 제70조가 요구하는 양립 불가능 요건을 충족하지 못한다. 또한, 소송계속 중 예비적 피고를 추가하기 위해서는 제70조 제1항의 요건을 갖추어야 하는데, 본 사안은 이에 해당하지 않는다.

V. 결론

- 원고 甲이 丙을 예비적 피고로 추가하는 것은 민사소송법 제70조 제1항 소정의 예비적 공동소송 요건(법률상 양립 불가능성)을 갖추지 못하였으므로 부적법하다. 따라서 법원은 甲의 피고 추가 신청을 각하하거나 허가하지 않아야 한다.